

1502741-65.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Marcos Fleury Silveira de Alvarenga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA INCREMENTO DA PENA-BASE DECLINADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE EVIDENCIADA. PENA REVISTA. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP

Processo nº:1502741-65.2022.8.26.0228 - C. 2022/000198 - Fls.

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1502741-65.2022.8.26.0228 - C. 2022/000198

Réu:

IGOR FERREIRA NASCIMENTO e outro

Réu Preso

Aos 23 de março de 2022, às 15:20h, na sala de audiências da 12ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, Comarca DE SÃO PAULO, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Marcos Fleury Silveira de Alvarenga, comigo escrevente a seu cargo, a final assinado, regularmente conectados à sala virtual, foi aberta a audiência, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, por meio de videoconferência criada no software Microsoft Teams, com a concordância das partes. Aberta, com as formalidades legais, observou-se no lobby da sala virtual, tendo se verificado a exitosa conexão do representante do Ministério Público, na pessoa do Dr. ORION PEREIRA DA COSTA, presentes os réus IGOR FERREIRA NASCIMENTO e WESLLEY ABREU FRÓZ, qualificados em apartado, a defesa na pessoa da Dra. PATRÍCIA LUCÍOLA DIAS DE MORAIS e do Dr. RICARDO LOBO DA LUZ, Defensores Públicos, pelo réu WESLLEY, e da Dra. ALINE MALDA MAIA ARAÚJO, OAB/SP 433.624 e Dra. LETÍCIA SILVA DA COSTA, OAB/SP 382.178, pelo acusado IGOR, a vítima FABRICIO JOSE MACIEIRA PINTO e as testemunhas MURILO DA CUNHA PELLIN, RE nº 161.627-7 e LUIZ DANIEL VIEIRA NOZZOLILLO, RE nº 195.092-4. Antes de iniciados os trabalhos, pela Defesa do acusado WESLLEY, foi ofertada resposta à acusação nos seguintes termos: a inocência do acusado será comprovada no curso da instrução criminal; arrola as testemunhas indicadas na denúncia. O Ministério Público manifestou-se pelo prosseguimento do feito. Pelo MM. Juiz foi dito: Não sendo caso de absolvição sumária, mantenho o recebimento da denúncia, por seus próprios fundamentos. Abertos os trabalhos, a pedido da vítima, que demonstrou receio e se sentiu constrangida em depor na presença dos réus, o MM. Juiz, com fundamento no artigo 217 do Código de Processo Penal, determinou que os acusados IGOR e WESLLEY fossem retirados da sala e apresentados àquela, em sala própria, como números 01 e 02, respectivamente, juntamente com outros dois indivíduos não identificados, como números 03 e 04, em sala própria para reconhecimento. Após, foi colhido pelo sistema de captação de

áudio e vídeo o depoimento vítima e das testemunhas de acusação e, em seguida, foram os réus interrogados, também pelo sistema de gravação de áudio e vídeo, sendo a ele dada a oportunidade de se entrevistar reservadamente com seu defensor antes da realização do ato. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito que: Indagado às partes sobre eventuais diligências nos termos do artigo 402 do CPP, nada foi requerido. Diante disso, declaro encerrada a Instrução e dou a palavra às partes para alegações finais.

Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, pelo mesmo foi dito: MM. Juiz, Inicialmente ADITO a denúncia para constar que os fatos ocorreram em 02 de fevereiro de 2022 e não como grafado na peça inicial. autoria restou efetivamente comprovada e a materialidade vem representada pelo auto de apreensão. A prova oral não deixa qualquer dúvida sobre a autoria. A vítima Fabricio relata que foi chamado por vizinhos, afirmando que estavam invadindo a casa de seus pais. No local deparou-se com a polícia e os dois réus presos, a quem reconheceu sem sombra de dúvidas. Afirma que uma corrente e um anel de ouro não foram recuperados. Os réus ingressaram por uma janela do banheiro superior, retratada a fls. 171. Os policiais Murilo e Luiz Daniel afirmaram que durante o patrulhamento foram informados sobre o furto e no local depararam-se com os réus pulando o muro da casa para o lado de fora. Os réus correram um para cada lado, sendo os dois perseguidos. Um foi pego ao lado da residência e outro um pouco mais á frente. Interrogados os réus admitiram parcialmente a prática do delito, apresentando versão que não encontra amparo na prova produzida, revestida de pouca credibilidade ao afirmarem que fugiram sem levar nada da casa. A prova obtida durante a instrução é suficiente para um decreto condenatório. A versão da vítima e dos policiais é uniforme e coerente desde a fase inquisitiva, devendo serem aceitas sem reservas, pois não conheciam o acusado anteriormente, não havendo razão para imputar falsamente a acusação. Cumpre destacar, neste contexto, as declarações da vítima, as quais, em crimes desta natureza, assumem papel de vital importância na elucidação da autoria do delito. Realmente, não é razoável supor que alguém, sem qualquer motivo concreto, o faça para prejudicá-la perante as autoridades constituídas. O mesmo se diga em relação aos agentes policiais que merecem credibilidade quando depõem em juízo dando conta do trabalho desenvolvido, pois agem em razão da função pública, presumindo-se deste modo, a lisura de seu trabalho, até prova em contrário. A prisão em flagrante dos réus é indicativo certo de autoria O crime se consumou, pois os bens não foram recuperados. As qualificadoras estão demonstradas pelo laudo pericial e o concurso de agentes. Os acusados são reincidentes, conforme certidões, circunstância que deve ser levada em conta na aplicação da pena, com fixação do regime inicial fechado para seu cumprimento. Nesses termos, aguarda-se a procedência da ação penal.

Dada a palavra à Dra. Defensora, pelo acusado IGOR, foi dito: IGOR FERREIRA DO NASCIMENTO, devidamente qualificado nos autos da Ação Penal em epígrafe, através de seus advogados que estas subscrevem, vêm, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, apresentar ALEGAÇÕES FINAIS NA FORMA DE MEMORIAIS nas razões fáticas e jurídicas a seguir expostas: Consta do Inquérito Policial que no dia 02 de fevereiro de 2022 por volta das 15:30hrs o Acusado na Rua João Gomes Batista, nº 400, Cidade Ademar, São Paulo/SP juntamente com o corréu Wesley supostamente subtraíram para si os bens da vítima Fabrício José Macieira Pinto. Posto isto, à luz do domus litis, o respeitável Representante do Ministério Público denunciou IGOR FERREIRA NASCIMENTO, por ter incorrido, em tese, no disposto no artigo 155, § 4º, incisos I, II e IV do Código Penal. Realizada audiência de instrução, debates e julgamentos no 23 de março de 2022, sendo ouvidas todas as partes. É a síntese do necessário. DO DIREITO. DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - DA NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA E DA CONTRADIÇÃO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. Dispõe o artigo 158 do Código de Processo Penal que: Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do Acusado. Posto isto, registra-se que o exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas

infrações que deixam vestígios, sendo este inclusive entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Somente se justifica a dispensa da prova técnica em hipóteses excepcionais nas quais a perícia tenha se tornado inviável, o que não ocorreu no caso em apreço, pois, sem nenhuma justificativa idônea o exame pericial não foi realizado. Primeiro ponto que merece destaque, é que conforme verifica-se dos autos o Acusado não arrombou a referida janela, sendo indicado pela própria vítima que ela estava aberta, não havendo como se falar em rompimento de obstáculo. Além disso, devemos levar em consideração que para a caracterização da qualificadora "deve haver dano concreto do obstáculo, simples estragos não configuram a qualificadora", além de ser necessário o exame pericial para comprovar o dano concreto, conforme pacificado em nossa jurisprudência para o reconhecimento da qualificadora. Veja, no caso em comento não houve de fato uma perícia na janela para comprovar o efetivo dano, e sequer há como comprovar tal afirmação através das fotos apresentadas pela vítima, uma vez que esta afirmou veemente que a janela estava ABERTA. Ao contrário do que sugere o depoimento dos Policiais Militares e da vítima, não houve o arrombamento. Sendo assim, é inaplicável a qualificadora de rompimento de obstáculo, conforme os fundamentos descritos. Desta feita, resta cristalino que não houve o real rompimento do obstáculo, o qual é indispensável para aplicação da qualificadora. Veja, Excelência, que este é o entendimento adotado pelos Egrégios Tribunais de Justiça do País: "ACORDAM, em 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para, reclassificada a infração para o artigo 155 "caput" do Código Penal, reduzir as penas impostas ao apelante para esse delito para quatro meses e dez dias de reclusão e quatro dias-multa no valor unitário mínimo, mantido o mais. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.(...) Aliás, nesse sentido já se decidiu que "para a caracterização da qualificadora, deve haver dano concreto do obstáculo. Simples estragos não configuram a qualificadora (RT 535/33)". (TJSP; Apelação Criminal 0006015-23.2012.8.26.0306; Relator (a): João Morenghi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de José Bonifácio - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 25/11/2015; Data de Registro: 03/12/2015). Isto posto, requer desde já que não seja aplicada a qualificadora prevista no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, por ausência de destruição ou rompimento de obstáculo, uma vez que os Acusados sequer chegaram a mexer no veículo. DA DOSIMETRIA DA PENA. Posto isto, passa-se a tecer considerações acerca da dosimetria da pena, devendo ser considerado o disposto no artigo 68 do Código Penal, respeitando o procedimento trifásico. Da fixação da pena passe em seu mínimo legal. Registra-se que o dolo mostrou-se comum à espécie, devendo a pena ser fixada no mínimo legal. No caso em tela a pena-base deve ser aplicada no mínimo legal, uma vez que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal devem ser sopesadas favoravelmente aos Acusados, objetivando-se o exame: (i) da culpabilidade; (ii) dos antecedentes; (iii) da conduta social; (iv) da personalidade do agente; (v) dos motivos; (vi) das circunstâncias; (vii) das consequências do crime e, por fim, (viii) do comportamento da vítima. Vejamos, da análise dos elementos carreados aos autos, não há nenhum elemento em desfavor do Réu. Verifica-se, no entanto, que estes colaboraram com a instrução processual, apresentando justificativas e os esclarecimentos necessários ao regular prosseguimento do feito. No mais, a jurisprudência dominante do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação. Sendo assim, sobre a culpabilidade, a investida ousada ao patrimônio alheio, expressa exatamente o tipo penal. A periculosidade de ir contra o patrimônio alheio já está prevista como fazendo parte desse delito. No mais, é evidente que a prática deste delito para sua ocorrência é necessário que o agente se aproveite de algum momento de fraqueza da vítima, ou em via pública, dentro de um veículo, ou até mesmo de sua residência, para surpreendê-la sem ser visto. Ora, não há no caso em tela qualquer elemento objetivo, a conduta do réu não merece alto grau de reprovação, na medida em que não ultrapassou os atos próprios necessários do tipo, e quanto a sua conduta

social e a sua personalidade nada foi apurado, devendo ser levado em consideração que o réu não é reincidente e não possui maus antecedentes, razão pela qual a defesa pugna pela aplicação da pena base no mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos. Da ocorrência de agravantes e atenuantes. O Acusado não negou os fatos, pelo contrário ele confessou o ocorrido e os fatos que o levaram a cometer tal infração. Ora, a confissão é um fato processual que gera um ônus e um bônus para o réu. O ônus está no fato de que isso será utilizado contra ele como elemento de prova no momento da sentença. O bônus foi concedido pela lei e consiste na atenuação de sua pena. Não seria justo que o magistrado utilizasse a confissão apenas para condenar o réu, sem lhe conferir o bônus, qual seja, o reconhecimento da confissão. Conforme entendimento da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, quando tal manifestação for utilizada para fundamentar o juízo condenatório, mesmo que o réu tenha dela se retratado em juízo. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA INCREMENTO DA PENA-BASE DECLINADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE EVIDENCIADA. PENA REVISTA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. MAUS ANTECEDENTES E RECIDIVA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. 4. A teor do entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, quando tal manifestação for utilizada para fundamentar o juízo condenatório, mesmo que o réu tenha dela se retratado em juízo, como na hipótese dos autos. 5. No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". 6. Tratando-se de paciente que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica. 7. No caso, quanto ao réu Paulo Eduardo, percebe-se que o Magistrado processante reconheceu

a presença de um título condenatório a ser valorado na segunda fase da dosimetria, inexistindo, portanto, qualquer óbice à compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Dessa forma, evidenciada manifesta ilegalidade a exigir a intervenção excepcional desta Corte Superior de Justiça, deve ser revista a pena definida na sentença condenatória. 8. Conforme a dicção do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, não se cogita desproporcionalidade na fixação do regime prisional fechado, pois, malgrado tenha sido estabelecida pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, ambos os réus são reincidentes e ostentam maus antecedentes. 9. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, tão somente para reduzir a pena do paciente Paulo Eduardo a 6 anos e 2 meses de reclusão, mais 14 dias-multa, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório. (STJ - HC: 433543 SP 2018/0010431-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento:

22/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2018). Diante disso, por ter confessado espontaneamente o crime cometido, fazem jus ao benefício da atenuação da pena, conforme o artigo 65, III, do Código Penal. Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: III - ter o agente: d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime; No mais, há no caso em questão a Agravante pela reincidência, uma vez que o Acusado foi condenado anteriormente, porém esta deve ser compensada pela Atenuante da confissão espontânea. No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.341.370/MT a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". Além disso, tem-se decidido, também, que se tratando de Acusado que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica. Registra-se que tal entendimento é firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: "II - A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do habeas corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou entendimento no sentido da "possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressaltados os casos de multireincidência". (STJ, EDcl no AgRg no HC 588675/SC, Rel.: Min. Felix Fischer, Quinta Turma, Julgamento: 06/10/2020). AGRADO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 67 DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRADO DESPROVIDO. A col. Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.341.370/MT (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/4/2013), firmou entendimento segundo o qual "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência." Agrado interno desprovido.(STJ - AgInt no REsp: 1597950 SC 2016/0123122-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 27/09/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2016): HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES TENTADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE CONFIGURADA. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. REGIME. GRAVIDADE CONCRETA. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, se a confissão do acusado foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão ter sido espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo que tenha havido posterior retratação. 2. Quando do julgamento dos EREsp n. 1.154.752/RS (DJe 4/9/2012), a Terceira Seção deste Superior Tribunal pacificou o entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o artigo 67 do Código Penal. 3. Conforme sedimentada jurisprudência desta Corte, consolidada pela edição da Súmula n. 269, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais, como é o caso dos autos 4. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e proceder à compensação entre essa atenuante e a agravante da reincidência, reduzindo, por conseguinte, a reprimenda do paciente para 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 6 dias-multa. (STJ, HC 282.572/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti da Cruz, Sexta Turma, J: 16/10/2014, 03/11/2014). Além disso, devemos salientar que é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: A Jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que incide a atenuante prevista no art. 65, III, "d", quando a confissão do acusado, ainda que retratada ou parcial, seja utilizada para fundamentar a sua condenação, como ocorreu no caso em apreço (Súmula 545 do STJ). (STJ, HC 402.527/SP, 5ª Turma, rel. Ribeiro Dantas, 13/12/2018, v.u.). Sendo assim, nesta fase a pena deve manter-se no mínimo legal. Da ocorrência de causas de aumento e de diminuição da pena. Na terceira fase não há qualquer causa de aumento,

apenas uma causa de diminuição. O artigo 14, II, parágrafo único, dispõe que: "Art. 14 - Diz-se o crime: II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços." Nobre Julgador, conforme amplamente demonstrado nos autos os Acusados não consumaram o crime por situação alheia à sua vontade. Conforme amplamente comprovado nos autos o Acusado somente ingressou na residência e logo os policiais chegaram no local. Ademais, ambos os policiais afirmaram em seus depoimentos que ao chegarem no local visualizaram ambos os Acusados pulando o muro e não perderam eles de vista, e não viram eles jogando qualquer objeto fora, e que nada da vítima foi encontrado com eles. Posto isto, nesta última fase, a pena de 2 (dois) anos deverá ser diminuída no máximo previsto, qual seja, dois terços, diminuindo 16 meses, ficando a pena em 8 meses de reclusão. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. Por todo exposto até o momento, caso este MM. Juízo ainda entenda pela condenação a pena privativa de liberdade, verifica-se que a reprimenda deverá ser cumprida em regime aberto, conforme previsto no artigo 33, do Código de Processo Penal. Vejamos: Registra-se que conforme se verifica da leitura das súmulas 718 e 719 do Colendo Supremo Tribunal Federal o julgador não pode justificar a aplicação do regime mais gravoso do que aquele previsto em lei com base apenas na gravidade abstrata do delito, bem como não poderá fazer uso de fórmulas genéricas em sua fundamentação, sendo necessária motivação idônea para amparar tal decreto. Súmula 718 do Supremo Tribunal Federal - A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. Súmula 719 do Supremo Tribunal de Justiça - A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. Além disso, caso entenda pela aplicação da pena-base no mínimo legal, estabelece a Súmula 440 que: Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. Sendo assim, resta evidente que o regime para cumprimento de pena do Acusado deve ser o regime aberto conforme o artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal. c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Caso este Nobre Julgador não entenda pelo regime aberto em decorrência da reincidência, deverá ser aplicado no máximo o regime semiaberto para o caso. DOS PEDIDOS. (I) Que seja afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo, tendo em vista que não fora realizada perícia conforme artigo 158 do Código de Processo Penal, bem como não há qualquer prova segura nos autos que comprovem o ocorrido. Que seja afastada a qualificadora de escalada prevista no artigo 155, § 4º, inciso II do Código Penal. (II) Que seja na primeira fase aplicada a pena-base no mínimo legal, uma vez que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal devem ser sopesadas favoravelmente aos Acusados. (III) Que seja na segunda fase aplicada a Atenuante da confissão espontânea, conforme o artigo 65, III, do Código Penal, bem como que esta seja compensada com a Agravante da Reincidência para o Acusado devendo a pena permanecer no patamar mínimo legal. (IV) Que seja na terceira fase a pena diminuída no máximo previsto no artigo 14, II, parágrafo único do Código Penal, qual seja, dois terços. (V) Que seja aplicado o regime aberto para os Acusados, ou caso este MM. Juízo não entenda, seja aplicado o regime semiaberto em razão da reincidência, conforme o artigo 33, § 2º, "b" e "c", do Código Penal. Termos em que, Pede deferimento.

Dada a palavra à Dr. Defensor, pelo acusado WESLLEY, foi dito: MM. Juiz, ofereço debates oralmente.

Pelo MM. Juiz, foi proferida a seguinte decisão: Vistos. IGOR FERREIRA NASCIMENTO e WESLLEY ABREU FRÓZ, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, § 4º, I, II e IV, do Código Penal, porque no dia 2 de fevereiro de 2021, por volta das 15hs30min, na rua João Gomes Batista, 400, Cidade Ademar, nesta capital, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios, subtraíram para

proveito comum, mediante escalada e rompimento de obstáculo, um anel e uma corrente dourados, do interior da residência da vítima FJMP, conforme boletim de ocorrência 484/2022 (fls. 2/5, 84/86) e imagens de fls. 63/75. Recebida a denúncia, citados, apresentaram defesa preliminar. Mantido o recebimento da denúncia, durante a instrução criminal ouvidas a vítima e testemunhas comuns, afinal interrogados os denunciados. Em alegações finais manifestou-se o Ministério Público pela procedência da denúncia, uma vez demonstradas a autoria e materialidade delitiva. As Defesas, a seu turno, pugnando pelas absolvições dos réus, de início apontaram a fragilidade do conjunto probatório a autorizar uma condenação; em caso de entendimento diverso, que acolhidas as demais teses. É o relatório. DECIDO. A ação penal é parcialmente procedente. Com efeito, além de presos em flagrante delito a conferir em tese a certeza visual imediata do crime, interrogados em juízo, quiçá por arrependimento, no que relevante, confessos. Não bastasse, também expressamente reconhecidos pela vítima no que presenciou, bem como pelos policiais militares diretamente responsáveis pela ocorrência e prisão em flagrante, como aqueles surpreendidos já em fuga, pulando o muro de acesso à residência na qual desenvolviam o furto, afinal detidos ainda nas proximidades, nada sendo apreendido em poder dos réus. Nada existe para subtrair a credibilidade da prova incriminadora com relação aos acusados. Apenas, pela prova oral colhida em audiência sob o crivo do contraditório, bem como pelo laudo de fls. 169/173, cumpre afastar as qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo, não demonstradas, vigando o concurso de pessoas. Em que pese o r. entendimento, não há como se entender pela tentativa, considerando não só a prova oral colhida em juízo, como também as imagens de fls. 63/75 e o laudo de fls. 169/173, a demonstrar nitidamente que os acusados efetivamente ingressaram na residência, onde tiveram a oportunidade de revirar ao menos um dos quartos (fls. 172/173). Ninguém tinha interesse em acusar pessoas desconhecidas. A materialidade delitiva encontra-se firmemente consubstanciada no BO de fls. 2/5, imagens de fls. 63/75 e laudo de fls. 169/173. Isto posto e considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a denúncia de fls. 136/137 para condenar os réus IGOR FERREIRA NASCIMENTO e WESLEY ABREU FRÓZ, qualificados nos autos, como incursos nas penas do art. 155, § 4º, inciso IV (concurso de pessoas), do Código Penal; absolvendo-os de também incursos nos incisos I e II, com fundamento no artigo 386, V, do CPP. Possuidores de condições subjetivas e objetivas bastante similares, vez que ambos confessos e reincidentes, com relação a ambos, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, em especial aos antecedentes, natureza, circunstâncias e consequências do delito, também considerada numa segunda fase as confissões compensando-as com as reincidências (fls. 87/89, 90/93), fixo-lhes as penas bases em dois (02) anos de reclusão, regime semiaberto, e pagamento de dez (10) dias-multa, no mínimo legal, tornando-as definitivas neste patamar por ausentes outras circunstâncias modificadoras das penas. Considerados os antecedentes e condenações, para ambos, inviável substituição da pena privativa nos moldes dos artigos 44 e 77 do CP. Presos em flagrante, convertida em preventiva, nesta condição tendo respondido ao processo, a esta altura condenados no regime semiaberto, não fazem jus ao benefício de recorrer em liberdade. Assim, garantida a ordem pública. Após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados. Custas na forma da lei. Publicada em audiência, intimadas as partes, registre-se e cumpra-se. Neste ato, sem recurso do Ministério Público, recorrem as Defesas e réus. Recebidos os recursos, processem-se com vista às Defesas. Saem os presentes intimados. Lido e achado conforme, vai devidamente por mim assinado. Nada mais. Eu, \_\_\_\_\_ ROGERIO ALVES DA SILVA, digitei.

Marcos Fleury Silveira de Alvarenga  
Juiz de Direito

Link de acesso à gravação das mídias captadas, armazenadas pelo Sistema OneDrive:  
(copiar e colar no navegador)

[https://tjsp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rogeriod\\_tjsp\\_jus\\_br/EjJrtDoFKV1JqXp-0nSxr3YBeIAzB50QsBfMPcCW1Z75kw?e=wjqoGN](https://tjsp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rogeriod_tjsp_jus_br/EjJrtDoFKV1JqXp-0nSxr3YBeIAzB50QsBfMPcCW1Z75kw?e=wjqoGN)